

1500126-50.2022.8.26.0407

Classe: Inquérito Policial

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GUILHERME LOPES ALVES PEREIRA

Comarca: Osvaldo Cruz

Foro: Foro de Osvaldo Cruz

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 20/10/2022

... que para configuração do crime de tráfico não se faz necessário que sejam presenciados atos de comercialização ou movimento de usuários.

E esta desnecessidade ocorre em razão do tráfico de entorpecentes ser um delito de ação múltipla, admitindo várias condutas, como, "ter em depósito", "guardar", "transportar" e "trazer consigo" a substância entorpecente para fins de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osvaldo Cruz

Foro de Osvaldo Cruz

2ª Vara

Avenida Estados Unidos, 480, . - Jardim das Bandeiras

CEP: 17700-000 - Osvaldo Cruz - SP

Telefone: (18) 3528-1817 - E-mail: osvaldocruz2@tjsp.jus.br

1500126-50.2022.8.26.0407 - lauda

C O N C L U S Ã O

Em 20 de outubro de 2022 faço conclusão destes autos ao(à) Exmo(a). Sr(a). Dr(a). GUILHERME LOPES ALVES PEREIRA, MM. Juiz(a) de Direito.

SENTENÇA

Processo nº:

1500126-50.2022.8.26.0407

Classe - Assunto

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Averiguado:

VICTOR FERNANDO SANTOS MACEDO

Vistos.

O Ministério Público apresentou denúncia (fls. 48/51) em face de Victor Fernando Santos Macedo pela suposta prática dos seguintes fatos:

"Consta dos autos do incluso inquérito policial que, no dia 03 de janeiro de 2022, por volta das 16:00 horas, na Penitenciária de Osvaldo Cruz, situada na Rodovia SP294, Km 572, Venda Branca, neste Município e Comarca, VICTOR FERNANDO SANTOS MACEDO, qualificado a fls. 13, transportava e trazia consigo, quando foi surpreendido tentando ingressar na unidade prisional referida, o total de 10 (dez) porções de "maconha", pesando 39,27 gramas, para entrega a consumo de terceiro, sem autorização em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 05 e laudo toxicológico definitivo de fls. 21/23. Apurou-se que o denunciado se trata de detento cumprindo pena no aludido presídio. No dia e hora dos fatos, ao retornar da saída temporária do final de ano (Natal/2021 e Ano Novo/2022), submetido aos procedimentos de segurança junto ao setor de revista por meio de aparelho de escâner corporal (Body Scanner), foi surpreendido tentando ingressar na unidade prisional de Osvaldo Cruz em poder de substância entorpecente supracitada.

Na ocasião, os agentes indagaram o denunciado, que a eles "admitiu que havia

ingerido porções de maconha e que estava tentando entrar no complexo criminal com elas", expelindo espontaneamente pela boca 10 (dez) porções de substância semelhante a "maconha", acondicionadas em material plástico.

Os fatos foram informados à Unidade Policial para as providências pertinentes. Logo, diante da quantidade da droga apreendida, bem como da forma como estava acondicionada, além das circunstâncias fáticas, mormente a própria confissão do denunciado que estava levando a droga para o interior da Unidade Penitenciária de Osvaldo Cruz, onde cumpre pena corporal, considerando, ainda, que se encontra cumprindo penal por tráfico ilícito de drogas (fls. 24/30), resta evidenciado que os entorpecentes se destinavam a mercancia."

A denúncia foi recebida em 08/09/2022 (fls. 78).

Devidamente citado, o réu apresentou resposta à acusação (fls. 70). Não foi concedida absolvição sumária (fls. 78).

Na audiência de instrução e julgamento, nesta data, foram ouvidas as testemunhas, sendo, após, interrogado o réu.

Na fase do artigo 402 do CPP, as partes nada requereram.

Em alegações finais orais o Ministério Público requereu a condenação e a Defesa pugnou pela desclassificação.

Após alegações finais orais gravadas via audiovisual, passei à sentença.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Presentes os pressupostos processuais, bem como as condições da ação, e não havendo nenhuma nulidade a ser sanada de ofício, passo ao exame do mérito.

No mérito, a ação penal é procedente.

A materialidade resta-se comprovada por meio do termo de ocorrência (fls. 03/04); auto de apreensão (fls. 05); laudo pericial (fls. 21/23); bem como pela prova oral colhida em Juízo.

A autoria delitiva também resta-se demonstrada, sobretudo pela prova oral colhida em Juízo.

A testemunha Marcel Alessandro Valessi, Agente de segurança penitenciária, em seu depoimento judicial, relatou que assim que passou pelo scanner corporal o réu estava com imagens diferentes na região do estômago. Passaram mais de uma vez. Perguntaram ao réu e este confessou que tinha ingerido as porções. O réu disse que se fosse fornecida água ele conseguiria expelir. O réu expeliu 10 porções de maconha. Não disse o destino. O réu estava preso e estava em saída temporária.

A testemunha Ivaldo Luís Possari Rodrigues, Agente de segurança penitenciária, em seu depoimento judicial, relatou que o réu no retorno da saída temporária foi passado no scanner corporal. Viram algumas imagens estranhas. O réu confessou que tinha ingerido as drogas. O réu expeliu alguns invólucros de cor preta.

Outrossim, nem se diga que os depoimentos prestados pelos Agentes Penitenciários são indignos ou suspeitos de credibilidade, eis que não possuem motivo algum para incriminar falsamente o denunciado. Além disso, nada há de concreto nos autos que pudesse desmerecer essa prova. Assim já se manifestou o Colendo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus nº 73518/SP, 1ª T., Relator Ministro Celso de Mello, j. 26/03/96, Dje 18/10/96). Ademais, a Suprema Corte firmou o entendimento no sentido de que não há irregularidade no fato de os policiais que participaram das diligências ou da prisão em flagrante serem ouvidos como testemunha. (RHC 108.586, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 9-8-2011, 1ª T, DJE de 8- 9-2011). No mesmo sentido, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça: Habeas Corpus 223086/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, j. em 19/11/2013.

É neste mesmo sentido o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: TJ-SP - APL: 00128093120148260196 SP 0012809-31.2014.8.26.0196, Relator: Airton Vieira, Data de Julgamento: 06/12/2016, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 09/12/2016; TJ-SP - APR: 00000257420178260274 SP 0000025-74.2017.8.26.0274, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 29/10/2020, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 29/10/2020.

Interrogado judicialmente, o réu confessou, em parte, os fatos. Disse que é usuário de maconha.

Esse é o conjunto probatório, por meio do qual os fatos estão cabalmente provados. Tem-se, portanto, não apenas indícios, mas sim um firme e uníssono conjunto

probatório que permite concluir, que o acusado cometeu o crime pelo qual foi denunciado.

As formas de acondicionamento das drogas apreendidas, bem como sua quantidade, denotam, às claras, sua predisposição: entrega a consumo de terceiros, o que torna inexorável a adequação típica da conduta ao crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.

Com efeito, faz-se necessário ressaltar, inicialmente, que a demonstração da destinação comercial das drogas não está imprescindivelmente vinculada à flagrância de ato de mercancia de narcóticos. Não se pode olvidar que para configuração do crime de tráfico não se faz necessário que sejam presenciados atos de comercialização ou movimento de usuários.

E esta desnecessidade ocorre em razão do tráfico de entorpecentes ser um delito de ação múltipla, admitindo várias condutas, como, "ter em depósito", "guardar", "transportar" e "trazer consigo" a substância entorpecente para fins de tráfico.

É neste sentido a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de São Paulo: TJ-SP -

APR: 00020744320158260441 SP 0002074-43.2015.8.26.0441, Relator: Lauro Mens de Mello, Data de Julgamento: 18/12/2020, 6ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 18/12/2020; TJ-SP - APR: 00662402520178260050 SP 0066240-

25.2017.8.26.0050, Relator: Lauro Mens de Mello, Data de Julgamento: 19/01/2021, 6ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 19/01/2021.

O réu tentou ingressar no estabelecimento prisional, após retornar de uma saída temporária, com drogas em seu estômago, sendo que, somente por meio escâner corporal (Body Scanner) foi possível identificar as substâncias. Logo após a visualização, o réu expeliu 10 invólucros de maconha.

Razão não assiste à Defesa com relação à desclassificação para o crime do art. 28 da lei de drogas. Pelas circunstâncias do caso concreto verifico que a conduta do réu se enquadra no artigo 33, caput da Lei de Drogas, e não no artigo 28. Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal o Juiz deverá analisar os requisitos do § 2º do artigo 28 da Lei de regência. No caso em tela, pela forma que o réu tentou ingressar com as drogas na unidade prisional, além da forma como a droga estava parcelada, indicam o objetivo de traficância no interior do estabelecimento prisional. Razão pela qual não há como se proceder à desclassificação. É neste sentido o entendimento do E. Tribunal de Justiça de São Paulo: TJ-SP - APR: 00080935920178260291 SP 0008093-59.2017.8.26.0291, Relator: Ruy Alberto Leme Cavaleiro, Data de Julgamento: 20/02/2020, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 20/02/2020; TJ-SP - APR: 15031182420188260536 SP 1503118-24.2018.8.26.0536, Relator: Gilberto Ferreira da Cruz, Data de Julgamento: 01/10/2020, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 01/10/2020; TJ-SP - APR: 00012106020178260594 SP 0001210-60.2017.8.26.0594, Relator: Ivana David, Data de Julgamento: 26/02/2019, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 07/03/2019.

O termo drogas representa um branco a ser preenchido por norma específica. A Portaria SVS/MS n. 344/1998, em seu anexo, traz a lista de substâncias entorpecentes. Verifico que a substância apreendida (maconha) consta no rol. Portanto, se enquadra no conceito de droga.

O crime de tráfico de drogas é de conteúdo múltiplo e alternativo; a incidência em apenas uma das condutas nele enumeradas para configura a prática delitiva. Se da prova judicial denota-se a ocorrência de qualquer uma das condutas descritas no tipo penal, a condenação por prática do tráfico de drogas é imperativa, satisfeitas a autoria e materialidade.

O acusado era, ao tempo dos fatos, imputável, tinha plena consciência da antijuridicidade de sua conduta, bem como não há nenhuma excludente de ilicitude ou de culpabilidade que possa beneficiá-lo.

As provas são seguras e não deixam dúvidas que o acusado cometeu a conduta descrita na denúncia, devendo responder penalmente pelo praticado.

Assim, dos elementos informativos colhidos na investigação policial e, principalmente, da prova judicializada, não restam dúvidas quanto à prática do crime em questão, sendo imperiosa a aplicação de sanção penal.

Destarte, a prova oral colhida, desse modo, dá conta da autoria narrada na

denúncia, sendo certo que o réu praticou o crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei 11.343/06.

Passo à dosimetria da pena, nos termos do artigo 68 do CP:

Primeira fase: A culpabilidade deve ser valorada negativamente, uma vez que o réu tentou ingressar no estabelecimento prisional com drogas em seu estômago após o retorno de saída temporária. Portanto, aumento em 1/6 e fixo a pena em 05 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa.

Segunda fase: O réu é reincidente, nos termos do artigo 61, inciso I do Código Penal (processo nº 1520289-11.2019.8.26.0228, com trânsito em julgado para a Defesa em 11/02/2021 - fls. 59), razão pela qual agravo a pena-base em 1/6 e fixo a pena provisória em 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, e 680 dias-multa.

O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea pressupõe, além de espontaneidade da confissão, que seja completa e sem ressalvas, contribuindo, de fato, para a instrução do processo e elucidação dos fatos.

A confissão parcial ou qualificada desmerece o réu, porquanto não colabora com o desvendamento do fato, não fazendo jus o réu à mitigação de sua reprimenda.

Veja, o réu confessou apenas a que as drogas eram para uso pessoal, benesse que não atinge o fim a que se destina, a elucidação da verdade real.

Nos termos da súmula 545 do STJ, a confissão somente ensejará a redução na segunda fase da dosimetria, caso seja utilizada para a formação do convencimento do magistrado. O que não aconteceu no caso em tela.

Este é o entendimento do STJ e do TJSP:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. DESCABIMENTO. ROUBO. DOSIMETRIA. ART. 65, III, D, DO CÓDIGO PENAL - CP. ATENUANTE. CONFISSÃO PARCIAL NÃO UTILIZADA. REGIME PRISIONAL FECHADO. VIOLÊNCIA EXTREMADA. OUSADIA. PERICULOSIDADE. GRAVIDADE CONCRETA. MAIOR REPROVABILIDADE NA CONDUTA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente. 2. A confissão parcial dos fatos não foi utilizada para a formação do convencimento da Magistrada, a qual se valeu nos demais elementos probatórios colhidos nos autos. Dessa forma, não há falar em aplicação da referida atenuante. 3. A fixação de regime mais gravoso do que o imposto em razão da pena deve ser feita com base em fundamentação concreta, a partir das circunstâncias judiciais dispostas no art. 59 do Código Penal - CP ou de outro dado que demonstre a extrapolação da normalidade do tipo. In casu, o paciente abordou as vítimas em plena via pública, com extrema violência, socando a face de uma delas. Esses elementos, em conjunto, demonstram maior ousadia e elevada periculosidade, justificando, a aplicação do regime fechado. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 446035 SP 2018/0088764-3, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 05/06/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2018) - grifei.

TRIBUNAL DO JÚRI - SENTENÇA CONDENATÓRIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO - ART. 121, §§ 1º E 2º, INC. V, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA - CONSELHO DE SENTENÇA QUE JULGOU PRESENTES A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS, BEM COMO AS QUALIFICADORAS - DECISÃO PROFERIDA DE ACORDO COM A EVIDÊNCIA DOS AUTOS. REDUÇÃO DA PENA - IMPOSSIBILIDADE - REPRIMENDA APLICADA DE FORMA CORRETA, DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS. PENA BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO OS ANTECEDENTES CRIMINAIS. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO - IMPOSSIBILIDADE - CONFISSÃO QUALIFICADA QUE NÃO PODE SER CONSIDERADA - SÚMULA 545, DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, A CONFISSÃO QUALIFICADA É ADMITIDA QUANDO SERVE DE FUNDAMENTO PARA A DECISÃO. REGIME CORRETO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - APR: 00263133620118260576 SP 0026313-36.2011.8.26.0576, Relator: Ivana David, Data de Julgamento: 31/08/2021, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 31/08/2021) - grifei

Terceira fase: Há incidência da causa de aumento de pena previsto no art. 40, inciso III da Lei 11.343/06, uma vez que o crime foi cometido nas dependências de estabelecimentos prisionais. Razão pela qual aumento a pena em 1/6 e fixo a pena definitiva em 7 anos, 11 meses e 8 dias de reclusão, e 793 dias-multa.

Fixo o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos,

posto que ausentes elementos acerca da capacidade econômica do réu, nos termos dos artigos 49, §1º e 60, caput, ambos do CP.

Fixo o regime inicialmente fechado, nos termos do artigo 33, §2º do CP, haja vista a reincidência do réu.

O réu não preenche os requisitos do artigo 44, tampouco do artigo 77, ambos do Código Penal, de modo que não é caso de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nem de sua suspensão condicional, haja vista a reincidência do réu.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na denúncia para CONDENAR VICTOR FERNANDO SANTOS MACEDO como incurso nas sanções do art. 33 da Lei 11.343/06, às penas de 07 anos, 11 meses e 08 dias de reclusão a serem cumpridas em regime inicialmente fechado, e 793 dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Deixo de decretar a prisão preventiva.

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais. Observe-se a assistência judiciária gratuita, uma vez que lhe foi nomeado Defensor pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo.

Proceda-se à destruição do restante da droga apreendida, nos termos do artigo 72 da lei 11343/06, se for o caso.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão: Proceda-se ao recolhimento da pena pecuniária, nos termos do artigo 686 do CPP e do artigo 50 do CP;

Comunique-se a Justiça Eleitoral para cumprimento da determinação do artigo 15, III da CF/88; Oficie-se ao IIRGD dando ciência acerca desta decisão; Expeça-se guias definitivas de execução penal; Expeça-se certidão de honorários advocatícios previsto na tabela do convênio DPE/OAB para o procedimento em espécie.

Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

Sentença lida e publicada em audiência, saindo as partes dela intimadas.

Osvaldo Cruz, 20 de outubro de 2022.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME LOPES ALVES PEREIRA

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA